

知网个人查重服务报告单 (全文标明引文)

报告编号:BC2026041215051715155788555

检测时间:2026-04-12 15:05:17

篇名: 以物抵债执行和解协议的救济路径类型化研究

作者: 张益鸣

检测类型: 期刊投稿

比对截止日期: 2026-04-12

检测结果

去除本人文献复制比: 8% 去除引用文献复制比: 1.4% 总文字复制比: 8%
单篇最大文字复制比: 1.3% (破产程序中以房抵债法律问题研究)

重复字符数: [1547] 单篇最大重复字符数: [260] 总字符数: [19387]

12.1%(1018) 12.1%(1018) 以物抵债执行和解协议的救济路径类型化研究_第1部分 (总8418字)
5.1%(426) 5.1%(426) 以物抵债执行和解协议的救济路径类型化研究_第2部分 (总8339字)
3.9%(103) 3.9%(103) 以物抵债执行和解协议的救济路径类型化研究_第3部分 (总2630字)



1. 以物抵债执行和解协议的救济路径类型化研究_第1部分 总字符数: 8418

相似文献列表

去除本人文献复制比: 12.1%(1018) 去除引用文献复制比: 2.4%(201) 文字复制比: 12.1%(1018)

1	<u>破产程序中以房抵债法律问题研究</u> 杨斌(导师: 杨玉梅) - 《云南师范大学硕士论文》 - 2024-05-30	3.1% (260) 是否引证: 否
2	中银推荐 以物抵债合同效力裁判规则(最高法院案例). - 《网络 (https://www.360docs.) 》 - 2024	3.1% (258) 是否引证: 否
3	<u>债务清偿期届满后以物抵债协议的性质与履行</u> 司伟; - 《人民司法(案例)》 - 2018-01-15	3.0% (252) 是否引证: 否
4	<u>债务清偿期届满后的以物抵债纠纷裁判若干疑难问题思考</u> 司伟; - 《法律适用》 - 2017-09-01	2.8% (236) 是否引证: 是
5	司伟: 债务清偿期届满后以物抵债若干疑难问题 民商辛说 - 《互联网文档资源 (http://www.360doc.co) 》 - 2018	2.8% (235) 是否引证: 否
6	<u>民事执行和解协议不履行的救济方式研究</u> 张琦(导师: 邓继好) - 《华东政法大学硕士论文》 - 2021-06-11	2.6% (219) 是否引证: 否
7	<u>日本民事执行强制管理制度研究</u> 王冷鑫(导师: 张小红) - 《上海外国语大学硕士论文》 - 2025-06-01	2.3% (193) 是否引证: 否
8	<u>抵押物流拍后 银行如何处置更妥当</u> 于飞 - 《中国城乡金融报》 - 2016-08-30	2.3% (192) 是否引证: 否
9	<u>论以物抵债协议的类型化适用</u> 李玉林; - 《法律科学(西北政法大学学报)》 - 2023-06-02 12:07	2.3% (191) 是否引证: 否
10	<u>解决现金清收问题的有效方法</u> 王祥;杨晓琳;张瀛澍; - 《中国邮政》 - 2019-11-01	2.1% (174) 是否引证: 否
11	<u>民事执行强制管理制度研究</u> 黄爱东(导师: 张永泉) - 《苏州大学硕士论文》 - 2021-08-01	1.8% (151) 是否引证: 否

12	怎样执行按份共有的房产？_深圳马成律师团 - 《网络（ http://blog.sina.com ）》 - 2015	1.7%（146） 是否引证：否
13	A公司与汤某房屋买卖合同纠纷案分析 刘明新(导师：刘玲;董良苍) - 《河北科技大学硕士学位论文》 - 2024-05-01	1.7%（142） 是否引证：否
14	执行程序中对被执行人宅基地上房屋的处置 陈荃； - 《人民司法(应用)》 - 2018-12-05	1.7%（142） 是否引证：否
15	30万欠款用价值60余万土地偿还 本报记者 甘仕恩 - 《云南法制报》 - 2021-09-13	1.5%（126） 是否引证：否
16	执行和解协议的类型化研究 高丽(导师：邓继好) - 《华东政法大学硕士学位论文》 - 2021-06-11	1.3%（113） 是否引证：否
17	论《物权法》第28条中“法律文书”的涵义与类型 王明华； - 《法学论坛》 - 2012-09-10	1.2%（103） 是否引证：否
18	狭义上的以物抵债协议的履行问题研究 戴新毅;陈岩； - 《北京政法职业学院学报》 - 2024-06-15	1.1%（89） 是否引证：否
19	论体制转型期执行和解的法律效力 百晓锋； - 《国家检察官学院学报》 - 2021-05-10	1.0%（88） 是否引证：否
20	以物抵债协议的性质与履行 王涛； - 《安康学院学报》 - 2020-02-20	0.8%（68） 是否引证：否
21	论以物抵债的性质及效力 殷晓琳(导师：关涛) - 《烟台大学硕士学位论文》 - 2021-06-08	0.8%（65） 是否引证：否
22	债权已届清偿期的以物抵债研究 杨磊(导师：汪军民) - 《中南财经政法大学硕士学位论文》 - 2022-05-26	0.5%（45） 是否引证：否
23	执行和解担保制度之适用困境及其纾解 张海燕； - 《中国政法大学学报》 - 2023-03-10	0.5%（45） 是否引证：否
24	民事执行契约研究 林洋(导师：赵泽君) - 《西南政法大学博士论文》 - 2019-03-14	0.4%（36） 是否引证：否
25	我国民事执行和解制度的困境与出路 黄光前(导师：李双元) - 《湖南师范大学硕士学位论文》 - 2011-11-01	0.4%（31） 是否引证：否
26	以物抵债协议类型化及其规则适用研究 陈韵盛(导师：易波) - 《东南大学硕士学位论文》 - 2024-05-10	0.4%（30） 是否引证：否

原文内容

以物抵债执行和解协议的救济路径类型化研究

张益鸣

摘要

《执行和解规定》第9条对申请执行人在对方违约时究竟是选择恢复执行还是另行起诉留有很大模糊。以物抵债作为执行和解协议的惯常方式，在解释论上通过对以物抵债协议、和解合同、执行和解等性质的复合分析后可以看出作为其融合体的以物抵债执行和解协议固有的流动性。具体而言，当事人在实体法上可以对判决确定后的权利义务重新安排，也可以对违约救济条款予以特定，就实体法新旧债性质而言可以划分为新债清偿（处分型）执行和解协议与债务更新（创设型）执行和解协议。与之相对应，为了维持实体程序权利义务的逻辑连贯性，前者应当以恢复执行为原则，另诉需要当事人以明确的程序契约来维护正当性，后者则仅能就新债另行起诉。立法论上，为了平衡被执行人和申请执行人的利益，避免过度保护被执行人，同时兼顾到申请执行人的审级利益，甚至可以在维护后者程序保障的基础上有限承认债务更新型执行和解协议之执行力。

关键词：以物抵债；执行和解协议；新债清偿；恢复执行；执行力

一、问题的引入

2020年修正的《最高人民法院关于执行和解若干问题的规定》（以下简称《执行和解规定》）第9条规定了申请执行人于被申请执行人不履行执行和解协议时既可以选择恢复执行也可以就执行和解协议另诉这两条路径。但是在争议发生时具体选择哪条救济路径仍然缺乏明确的标准，并且根据当事人对实体权利义务与程序权利的重新安排不同结果对法定程序权利会造成相应的后果。以物抵债是执行和解中最为典型的一种形态。根据以物抵债产生的原因为标准，可分类为双方当事人合意的以物抵债与司法拍卖、变卖不成法院强制以物抵债。《民诉解释》489条规定自愿以物抵债：“经申请执行人和被执行人同意，且不损害其他债权人合法权益和社会公共利益的，人民法院可以不经拍卖，变卖，直接将被执行人的财产作价交申请执行人抵偿债务，对剩余债务，被执行人应当继续清偿。”它属于执行和解的一种方式。《民诉解释》490条规定强制以物抵债：“被执行人的财产无法拍卖或变卖的，经申请执行人同意，且不损害其他债权人合法权益和社会公共利益的，人民法院可以将该项财产作价后交付

申请执行人抵偿债务，或者交付申请执行人管理；申请执行人拒绝接收或管理的，退回被执行人。”在强制以物抵债中，对抵债物的处理以法院为主导，私人意思自治很难得到体现。以物抵债执行和解协议作为自愿以物抵债的书面体现，它可以仅变更原生效裁判确定债务的履行方式、履行期限等，更有可能超出了原裁判确定的权利义务范围。对已生效判决确定的权利方案，应该得到不容置疑的、迅速的执行，因为从起诉受理到最后法院判决，其经受了程序正义与实质正义的检验，合理性与合法性得到了定在。然而法律同样尊重当事人在执行程序中通过执行和解在这定在之后根据现实情况对其确定的内容进行重新调整，使之得到了短暂的修正后的合理性与合法性。

本文所聚焦者，正是双方当事人合意的、发生于执行阶段的特殊形态——以物抵债执行和解协议。虽然存在“私契约不能变更公法”原理，但当事人对私权处分的自由不应被否定，作为公法的执行法应尊重这种实体法上的处分自由，至于如何尊重和保障就需要对该修正后的合理性与合法性进行法理层面以及现实履行方面的检验。在公私法关系理论指导下的执行和解制度，经过有机融合私法自治和公法强制，综合平衡协调公私利益，构成了执行过程中新型的法律机制。从履行结果来看，执行和解协议特殊的救济方式不属于纯粹的公力或私力救济，而是一种混合救济：于公而言，执行和解协议未得到履行从一开始的恢复原执行到现在多一种另行起诉，始终没有赋予执行和解协议本身执行力；于私而言，执行和解协议若得到完全履行，法院尊重当事人这一自由处分，对该案作结案处理。

但这样一种公私法交融的复合性质，也给理论与实践带来了难题。当事人既可以通过私法合意对判决确定的债权进行的处分（仅变更履行方式抑或以新债取代旧债），还能够对违约救济条款进行明确（约定仅能恢复执行、另诉或两者均可），若仅从单向度来认定以物抵债执行和解协议，则难免会忽视其实体程序权利交融时产生的复杂性，尤其是当事人自己选择限制自己的程序选择权或者对选择权的处分与实体处分类型发生错配，就可能会产生逻辑矛盾或者救济困境。因此，本文的问题意识在于，通过实体法与程序法的双重视角重新审视以物抵债执行和解协议的法律性质，同时厘清当事人进行实体程序处分与法定救济路径之间的内在关联，进而构建一个逻辑自治、标准明晰的类型化体系。

二、以物抵债执行和解协议的理论基础与性质辨析

（一）履行期间届满后以物抵债协议的“新债清偿”本质

以物抵债无论是学理上还是实践中，以债权人是否实际受领债务人的他种给付为标准可以分为代物清偿和狭义的，达成协议后抵债物现实交付了就是代物清偿，而仅达成抵债协议抵债物尚未交付即为狭义上的以物抵债。这一点也直接导向民法学者对以物抵债协议性质的争论，也即代物清偿说、债的更改说和新债清偿说。所谓代物清偿，是指以其他给付替代原给付，从而使债权消灭的债权人与给付人之间的契约。在我国，以物抵债仅是一种实践中双方当事人合意达成的债务履行变通方式，尚未获得明确的法律效力，其具体含义也没有通过立法进行规范和确认。当然，实践中由于代物清偿的要物性可以避免诺成说下债务人因债权人提出的不同给付请求权引起的纠纷，从防止纠纷的再生而言，代物清偿说有其优势。值得一提的是关于以物抵债协议诺成性与实践性的区分，以及以物抵债按设立时间为准，可以分为债务履行期限届满前的以物抵债和债务履行期限届满后的以物抵债。本文论及的属于执行和解阶段当事人达成的以物抵债协议，此时生效裁判文书确定的债务履行期限早已届满，故其属于债务履行期限届满后的以物抵债协议，学理上一般认定为诺成性合同，故代物清偿说因其要物性的特征与诺成性合同相悖，故不在本文考虑范围内。进一步说，采用代物清偿说也不符合执行法中“债权人中心主义”的执行程序观，例如在汤龙买卖合同纠纷案，债务人在无法偿还借款后，与债权人签订房屋买卖合同，并将对账确认的借款本息转变为已付购房款。嗣后债务人又不履行该房屋买卖合同，若采纳要物合同说，那么该合同无法成立，债权人无请求权，债权人也会丧失履行该合同及时实现债权的利益。且就执行和解中签订的以物抵债协议而言，若坚持其实践性的观点，仅当合同履行完毕后才成立，不免有无视当事人在执行和解过程中最初的变更判决确定之债的履行方式之表示而强行解释的嫌疑。

债务更新（或债的更改），是指设定新债务以代替旧债务，并且旧债务最终消灭的民事法律行为。债权人只享有新债权而并不享有旧债权。旧债权消灭，与其无同一性的新债权成立。从表面上，债务更新与代物清偿都消灭了原债务关系，并且均涉及对原定给付内容的变更。然而，两者存在本质区别：债之更改是通过消灭原债务并设立新债务的方式进行，债务人承担新的债务义务，但并不涉及即时履行，因此不属于要物契约。而代物清偿则是以另一种给付替代原定给付，该替代给付必须实际履行，因此属于要物契约。新债清偿，也被称为间接清偿或旧债新偿，德国债法称之为“为清偿的给付”，是指债务人因清偿旧债务而负担新债务，并因新债务的履行而使得旧债务消灭的民事法律行为。在此情形下，新旧债权并列，只有当新债权获得履行以后旧债权才会消灭。需要明确的是，对于该种以物抵债协议债的关系的讨论是基于原债务履行期间届满后这一时间段。至于新债与旧债的关系，笔者认为首先应当尊重当事人意思自治。考虑到实践的复杂性，同时避免为以后的立法或司法解释制定造成障碍，《合同编司法解释》27条第2款也有但书规定。再考虑到以物抵债中的“物”本身是广义的概念，而“债”则是狭义上的债，原则上仅限于金钱债务，因而新债清偿与债务更新的区别可以考察新债与旧债之间是否具有同一性，毕竟物包含动产、不动产、权利等在实践中复杂的情况。

在当事人对新债旧债关系约定不明的情况下，认定当事人于债务清偿期届满后达成的以物抵债协议的法律性质为“新债清偿”比较合适。于实证法上，《合同编司法解释》第27条第2款关于新旧两债关系的规定明确了这一点；于学理上，因保护债权的需要，债的更改一般需要有当事人明确消灭旧债的合意，原则上不适合通过“抵偿”等语义模糊的词语得出消灭旧债的结论。而认定为新债清偿则可以兼顾合同全面及时履行、诚实信用原则以及保护债权的理念。结合司法案例来看，当事人达成以物抵债协议大多想达成的效果是原债的清偿，非成立新债权债务关系，因为其使得债权人无法主张原债，对其非常不利。除非债权人自愿放弃其获得原债清偿的机会，也即符合其意思自治，那么适用债的更改规则自不在话下。

（二）和解合同的确认效与创设效

从实体法角度，和解合同具有“确认效”和“创设效”，根据实践中当事人合意的不同的情形，产生了各种各样性质的和解合同，但总体来说逃不出这两个范围。确认效和解合同从消极方面而言不允许当事人再主张和解前法律关系的内容，积极方面而言因其具有实质的约束力，可以在和解合同之诉中作为抗辩。创设效和解合同并非完全变更和解合同前当事人权利义务内容，更多的情形是既有对原来争议延续的部分，也有超出原争议的范畴，即不仅具有确认的效力，还具有创设的效力。这一实体法上的效力二分，为分析和解合同对原债权债务关系的影响提供了清晰的分析工具。确认效的核心在于固定与止争，它终结了此前的法律关系的不确定状态，使其内容得以明确（或者是对原争议债权的再确认），但并未改变债之同一性。而“创设效”则意味着和解合同在平息原有争议的同时，衍生出新的、独立的债权债务关系。至于新旧债关系何如，无法一刀切地判断，毕竟有时当事人创设的可能仅仅是对原债的另一种履行方式，有时也有可能在旧债基础上创设一种全新的担保物权或违约金

条款，而后者才是真正意义上的兼具确认与创设效的和解合同，需要法院加以甄别。在此要明确的是哪怕和解中产生了新的权利义务，也不意味着发生了债务更新，从而导致新旧债丧失同一性，即只有通过当事人契约自由的表示才能达成更新的效力。

（三）执行和解的公私法双重性质 因为法律规定上的模糊性，理论界和实务部门对执行和解的性质和效力有不同的理解、解释或主张，进而产生了私法行为说、诉讼行为说和一行两性质说等不同观点。对执行和解定性是确定其效力的前提，并且分析执行和解的性质有利于明确其对执行程序所造成的影响并构建对当事人的救济途径。本文采一行两性质说，即执行和解是具有双重属性的“特殊”行为，执行和解一方面调整了当事人间的私人实体法律关系，同时在表达自愿终结执行程序意志的时候需要法院介入的公法与私法融合的行为。就其公私性质而言，民事执行和解协议经司法审查确认其法律效力，实质上即当事人的意志经过公权力的检验，与国家意志相结合，得到了国家的承认。在双方达成和解协议后的这一阶段，和解协议只具有私法的效力；在司法审查确认其合法性后的这一阶段，其“法力”得到增强，和解协议的履行具有公法的效力，可以约束执行法院。从这样一种阶段动态运行的观点来看，执行和解可同时具有实体上和程序上的效力。这也符合实定法2023年《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称《民诉法》）第241条和《执行和解规定》第5条的规定。需要指出的是，对于执行和解法性质的讨论，可以说参考了日本关于诉讼上和解的研究。然而，必须清醒地认识到，执行和解制度与诉讼上和解在制度前提和核心功能上存在根本差异，对其进行性质界定时必须审慎考量这一背景。诉讼上和解发生于诉讼系属中、法院作出终局判决之前，其核心功能在于通过当事人在法官面前的合意，替代一个尚未形成的判决，从而终结诉讼。因此，法律直接赋予其与确定判决同等的效力（既判力与执行力），在法理上是顺理成章的。而执行和解则发生于已有生效裁判作为执行依据之后，在这一时间点至少在某些情形下与原生裁判确定的法律关系存在紧张关系。

诉讼上和解与执行和解从实体法律关系变更上看并没有本质上的区别，区别还是在于法院的审查或确认在存在或不存在一份已经生效的执行依据的介入究竟会导向何种不同结果。在诉讼和解中，其和解协议经过法院审查确认被制作成调解书后，当然具有既判力、执行力等公法上效力，若想颠覆它，则只能通过再审程序或执行异议等手段。虽然执行和解协议经过法院记入笔录加上签字盖章等确认后产生了执行中止等公法上的效果，但是执行和解协议仍然属于私文书，即使司法审查认定有效只不过是排除了私法上无效可撤销等事由，不会在性质上由公转私。但是考虑到执行和解协议在执行完毕后可以作结案处理，实际上与原生裁判是呈现出了两个执行依据的潜在状态（原执行依据仍然存在，可以恢复执行），当然这不同于直接赋予了执行和解协议以直接执行力，更为重要的考量也许是对执行目的的达成以及当事人意思自治的尊重。不过更为实质的介入还是当双方就执行和解协议发生争议时，法院此时必须考量其与原生裁判确定债权以及实体选择与程序选择的关系。质言之，在调解书中只有一次公权力的介入，而在执行和解协议中有两次公权力的介入，这导致后者在前后公权力的位阶上需要进一步综合考量实定法规范以及当事人具体情况才能明晰，尤其是在当事人对实体程序权利均作出处分时如何对接恢复执行或另行起诉的救济模式。

三、实体处分与程序约定维度下的以物抵债执行和解协议类型化构建

通过上述理论溯源，可以看出和解合同的确认效力与创设效力构成了实体基础，以物抵债的债的更改与新债清偿理论提供了核心的分析工具，而执行和解的公私法复合属性为该协议的程序运作提供了场域。尤其是和解合同与以物抵债协议内在趣旨存在交叉，而不同的实体定性，通过与执行和解的程序属性相结合，最终产生了不同类型的以物抵债执行和解协议。在此逻辑下，实体性质构成程序救济的制度前提。基于上述认识，本文采纳学界既有分类，

（一）基于新旧债实体法关系区分的新债清偿型与债务更新型执行和解协议 前文和解合同一般是以诉讼前或诉讼中签订这一时间段为前提，对于法院判决作出后而达成的执行和解协议，较少有实体法学者对于其关系做出论述，或者直接套用普通的“民事和解”性质理论。而在以物抵债协议的语境中，无论是新债清偿还是债务更新，其对于新债旧债关系的论述与和解中的确认效和创设效具有天然的内在关联，以至于在执行的场域内造成了藕断丝连的景观。在此，判决确认之债即旧债，当事人于以物抵债执行和解协议中达成的合意之债为新债，可以观察到该旧债与新债可能在既判力、一事不再理问题上存在紧张的关系。对于这一问题可以从既判力的基准时入手。既判力的适用存在时间范围，通说认为这一时间节点（或称为“标准时”，“既判力的时间界限”）为事实审言词辩论终结时，而辩论终结之后超出原民事法律关系发生的变动不受既判力的拘束。逆言之，作为既判力基准时后出现的以物抵债执行和解协议，其属于当事人通过法律行为变更而形成的新事实，故而并无违反既判力的危险。

然后需要考察新债与旧债与确认和创设之间的关系。在诉讼法层面上该新债属于“新事实”，是否也就意味着该以物抵债协议也产生了创设的效力？这需要根据协议不同性质来分别判断，不能一概而论，毕竟前诉既判力的遮断效果属于诉讼法层面的效果，不考虑实体层面的约定则有失偏颇。在新债清偿型以物抵债协议中，债的同一性并没有发生变更，原定金钱给付和新物之给付共同服务于原债权的清偿，即履行方式的变更并没有改变请求权的实质。按照旧实体法说，既然实体法上的请求权并没有发生变更，而仅仅是其履行方式发生变化，则当然诉讼标的是同一的，即此时仅有确认的效力，创设的并非新的请求权，而仅仅是新的履行方式。而在债务更新型以物抵债协议中，当事人对判决之债进行了实质性变更，前诉法律关系与后诉法律关系因债的基本要素不同而失去同一性，诉讼标的也根本不同。此时可以认为该种执行和解协议具有创设权利的效力。综合以上论述及部分学者作出的既有分类，可以认为对当事人自己的实体权利进行重新安排，在债的主体客体上并未超越原生裁判的，与之相对应的便是处分型（新债清偿型）执行和解协议；而对于执行和解协议中存在超出原判决文书确定的实体权利内容的，即为创设权利型（债务更新型）执行和解协议。总的来说，在当事人对新旧债关系有明确约定的情况下，新债清偿型执行和解协议，新旧债造成的法律效果实际上仍然在原判决范围内，既没有增加执行人的权利，也没有为被执行人新增义务，而只是一个履行方式的变通。而债务更新型执行和解协议在理论上的核心特征在于当事人通过明确约定以新的抵债物来替代原生裁判确定的金钱债权，意图在消灭原生裁判确认的执行债权基础上创设新的和解债权之给付义务。值得注意的是“债的更改”将从根本上动摇原执行依据的效力，对债权人的保障不足且风险极高，正因如此，在司法案例中，被明确认定为债务更新型执行和解协议极为罕见。对于当事人对新旧债没有明确约定的情形，应当被视为新债清偿型执行和解协议，这一解释路径不仅维系了原执行依据的稳定，也为当事人之间基于默示所形成的新权利义务关系提供了保障。

（二）基于违约救济条款程序约定的一般型与特殊型执行和解协议

目前学界还根据当事人在实体上与程序上的不同选择将执行和解协议进行了不同的分类，总的来说效力不存在瑕疵的执行和解协议分为一般和特殊两种类型。前者当事人既没有对实体也没有对程序权利进行明确的约定，而后者既有可能包括实体之债关系的明确约定（替代型执行和解协议），也有可能包括程序契约的合意（选择型执行和解协议）。这是一种偏向实体法的

分类，并且可以看出根据这一分类，其与新债清偿型、债务更新型执行和解协议的分类存在重叠。同样是一般和特殊，陈杭平教授偏重当事人对有无“违约救济条款”的程序安排角度出发，认为当事人对违约救济条款（申请恢复执行、另诉和申请执行和解协议）没有特殊约定，或者约定不明的，即为一般和解协议；有明确约定的，可认为特殊和解协议。本文在修正肖建国教授对实体权利义务安排的基础上，融合陈杭平教授关于违约救济条款程序的核心约定，以期同时在实体与程序维度对以物抵债执行和解协议进行类型化分析。因为尽管无论哪种分类都体现了对当事人选择的尊重，但若仅约定实体法或程序法的条款，而没有将两者均囊括在内，亦或者实体程序两种条款都包含在执行和解协议条款内，则能深入剖析以物抵债执行和解协议的完整面貌，并真正地救济模式对接起来。在此，根据实体与程序可能出现的不同情况，可以把以物抵债执行和解协议分为如下类别：实体法分为双方明确约定新债旧债并存、新债代替旧债和旧债关系约定不明，程序法分为约定仅可以另诉或仅可以申请恢复原执行、约定既可以另诉又可以恢复原执行和另诉与恢复执行约定不明，具体可以参见表1。

值得一提的是在此当事人对旧债关系以及程序的安排，都体现了某种程度上的选择。实体法上，债权人对债务人不履行以物抵债协议拥有选择权，该基础在于新债清偿的理论和实践。新债清偿说不要求以抵债物的现实交付为成立要件，认为当事人就以物抵债诺成即成立，那么新债在完全履行完毕之前，新债与旧债同时存续。也正是新债和原债处于并存状态，才有可能发生债务人不履行以物抵债协议时，债权人对履行新债和原债的选择权。然而，在新债未履行的情况下，允许债权人择一行使请求权造成双方权利义务失衡，尤其是加重债务人的负担，也即债务人在债权人确定要求其履行哪一债务之前，不得不既准备新债务又准备旧债务。而且债务人同债权人达成以物抵债协议实际上就是为了以他种给付代替原给付，由债务人履行新债既符合当事人签订合同的意思表示，也符合常理。因此哪怕合同中明确约定合同成立后债权人或债务人可以选择履行旧给付或替代给付，但当事人这种选择的可能应区别于选择之债所创设的选择权。这种特殊的选择权在约定之前旧债业已确定，只不过是明确了履行顺序，并不存在行使该权利之后使得给付内容特定的功能。同时笔者也认为选择之债的选择权用于此语境下存在一定的困境。具体在于《民法典》515条第2款规定选择之债的选择权在当事人之间的转移，以债务人首先有选择权为前提。以物抵债协议中关于新债履行与旧债履行之间的选择权，为保护债权而赋予债权人，不适用于债务人。换言之，基于意思自治和诚实信用原则，在达成以物抵债协议后，债务人应当先履行新债，而有权选择履行后债，即按照新债先于旧债的顺序履行，这也表明债务人本身并不存在所谓的“选择权”。既然如此，又何来515条所称“选择权转移至对方”？有学者也对选择之债的定性进行了批判，并认为将其视为任意之债更为合适。更有学者从保护债权人利益，强化完全受偿可能性出发，认为新旧债构成选择竞合关系，债权人的“选择请求”也不应落入选择之债的范围内。

2. 以物抵债执行和解协议的救济路径类型化研究_第2部分		总字符数：8339
相似文献列表		
去除本人文献复制比：5.1%(426) 去除引用文献复制比：0.8%(63) 文字复制比：5.1%(426)		
1	论执行和解申请执行人“双轨制”选择下的被执行人实体救济 张海燕；- 《暨南学报(哲学社会科学版)》- 2020-04-15	1.8% (151) 是否引证：是
2	和解制度所涉实体及程序问题研究 刘学在；- 《国家检察官学院学报》- 2016-03-10	1.7% (139) 是否引证：是
3	民事执行和解制度研究 雷修(导师：邓辉辉)- 《桂林电子科技大学硕士论文》- 2022-06-06	0.7% (55) 是否引证：否
4	民事执行中以物抵债的实证分析 叶丽玉(导师：黄宣)- 《西南政法大学硕士论文》- 2016-03-31	0.6% (46) 是否引证：否
5	论执行和解协议适用的困境和出路 李红晓(导师：闫庆霞)- 《暨南大学硕士论文》- 2020-06-11	0.5% (43) 是否引证：否
6	民事执行契约研究 林洋(导师：赵泽君)- 《西南政法大学博士论文》- 2019-03-14	0.5% (40) 是否引证：否
7	执行中对厂房土地的分割分宗处置 柯澄川；- 《人民司法》- 2021-10-15	0.4% (34) 是否引证：否
8	民事执行和解救济机制完善研究 李宇晴(导师：张悦)- 《辽宁大学硕士论文》- 2023-05-01	0.4% (33) 是否引证：否
9	执行债务人异议之诉研究 李珊(导师：唐力)- 《西南政法大学博士论文》- 2021-03-01	0.4% (32) 是否引证：否
10	执行和解协议违约救济研究 李希健(导师：郝振江)- 《上海财经大学硕士论文》- 2024-05-01	0.4% (32) 是否引证：否
11	论执行和解 - 豆丁网 - 《互联网文档资源(http://www.docin.com)》- 2016	0.4% (32) 是否引证：否
12	论我国先予执行制度的立法缺陷和完善 蔡伟珊(导师：张晋红)- 《广东商学院》- 2010-05-20	0.4% (32) 是否引证：否

13	论民事执行和解	朱纪彤(导师: 张永泉) - 《苏州大学硕士论文》 - 2019-06-01	0.4% (30)	是否引证: 否
14	关于民事执行和解制度的调查报告	宁全利(导师: 王杏飞) - 《西南政法大学硕士论文》 - 2016-03-19	0.3% (26)	是否引证: 否

原文内容

以上讨论都带有浓厚的实体法趣旨,对于以物抵债执行和解协议来说,尽管可以利用实体法上多种理论来解释执行债权与和解债权的关系,但若继续探求当事人对于执行契约的安排,则往往没有那么简单。《执行和解规定》从实定法层面提供了恢复执行和另行起诉两条路径,虽从文义解释上也无法得出该条规定属于强制性规定,需要法院根据现实情况来适用,且实践中更是没有排除当事人就救济条款进行自主安排,但当事人可以对这两者进行自主选择也存在与前述实体权利义务重新安排或法律规定矛盾的潜在危险,这点将在后文详细展开。

四、类型化视角下以物抵债执行和解协议的救济规则审视

(一) 救济模式运行的制度前提

1. 执行和解协议达成后执行中止

根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释(以下简称《民诉法解释》)第464条,在执行和解协议达成后程序上拥有暂时性中止或彻底终结强制执行的效果,这是“请求”加“裁定”所共同作用导致的,在比较法上可以被视为“取效诉讼行为”(是指无法直接产生诉讼法上的效果,必须经由法院裁判才能达成目的的诉讼行为,典型的取效诉讼行为是申请、主张和举证)。但有实务人士从强制执行追求效率,要求简明快捷的角度考虑,认为执行和解制度本身就身处公私法交界之处,互相渗透,再给其程序效果设置时间门槛容易把执行和解制度设计得烦扰庞杂。笔者认为目前理论界对于执行和解公私性质的承认过于火热,似乎想在任何制度设计方面都体现其公私结合的特征,但在程序方面完全没有必要思考得如此复杂。当事人和解协议一旦达成,就应该立即中止执行,而在当事人和而不懈时,那么就恢复原执行即可。

虽然仅从464条来看,达成执行和解协议后,执行程序并不当然地中止或者终结,申请执行人可以通过程序选择权来决定执行程序是否进行,但结合《执行和解规定》第2条则可以解释出不同的法律效果。具体而言执行和解只要满足三种情形之一的,人民法院可以裁定中止执行,无需当事人请求中止执行或者撤回执行,也应当发生中止执行的法律效力。当然这也带来了实践操作上的麻烦,因为当事人并不了解执行和解协议达成后这一急促的法律后果,因此需要执行法官行使释明权,向执行当事人释明执行和解与执行外和解在程序效力上的区别,这样才可以使得执行和解达成后中止执行的程序效果具有正当性。

2. 法院不得径行作出以物抵债裁定

《民法典》物权编解释(一)第7条对《民法典》229条中的“法律文书”做了限制性解释。作为非基于法律行为发生的物权变动,以物抵债裁定书不同于一般裁定书只处理程序问题,其还关系到当事人在实体法上的物权变动关系。结合程序法上原《民诉法解释》493条规定,但2022年修正的民诉法解释却删除了该条款,其个中缘由耐人寻味。也许是司法机关认为采用实体法中关于物权变动的条款已经足够解释所有权变动的情况,无需再通过程序法的司法解释进一步说明。

从理论上讲,对于合意以物抵债,若出具的以物抵债裁定书存在损害其他债权人利益的情况,可以援引民法典538、539条规定的债权人撤销权之诉,以撤销以物抵债裁定书;对于强制以物抵债,如果损害社会公共利益,也可以根据民法典153条第2款来认定以物抵债协议无效,并撤销以物抵债裁定。从实践角度看,自愿以物抵债本质上属于执行和解,执行法院不宜出具以物抵债裁定书,但强制以物抵债,执行法院可以出具以物抵债裁定书。司法实践有观点认为当事人自行变卖财产清偿债务当事人达成执行和解约定变更履行方式的具体内容,属于一种私法行为,该变卖行为并非由执行法院主持或掌控的执行处置行为。这可以看出法院对当事人合意以物抵债的风险存在担忧,在未经过国家机关背书或审查的私法行为,于情于理都不应该赋予其直接发生物权变动的效力。综合法条规范、理论与实践逻辑看来,以物抵债执行和解协议不宜由法院直接作出以物抵债裁定。

(二) 我国双轨制救济模式的理论反思与类型化适用

这一救济模式根源于《执行和解规定》第9条。从解释论的角度看,这一救济模式虽提供了“恢复执行”与“另行起诉”两种路径,但该规定并未明确二者的适用情形,导致司法实践中面临选择困境。法官在协议性质模糊时缺乏清晰的裁判指引,既可能产生类案异判的风险,也为当事人任意行使程序选择权时留下空间。以物抵债协议的性质等实体安排构成了当事人合意的核心内容,不仅直接决定了基础法律关系的构造,更直接导向了其对应的救济模式。若当事人仅对救济条款没有约定,根据后文类型化构建对应的救济途径进行救济即可。而若当事人主动限缩其救济模式,法院也应当尊重当事人的选择。不过若当事人主动约定的救济条款与其本应有的救济模式相违背,则法院可以无视这一约定,回归理性的救济框架。

1. 另行起诉的适用争议与功能定位

根据《执行和解规定》第2条,无论是在执行中达成的,还是在判决生效后申请执行前达成的执行和解协议,都必须经过人民法院审查确认才能成为真正的“执行和解协议”,并且具有可诉性。只不过需要注意的是这是建立在有限性基础上的可诉性。新增了另诉的救济途径并非得到了学者们的一致赞成,这种双轨制救济模式似乎存在一定困境:哪怕法律规范上增设另诉的救济途径,但在司法实践中对不履行执行和解协议的,申请执行人几乎是“只能”(因执行实务中对另案诉讼如何适用尚无明确把握,法院在很多情况下对申请执行人提出的另诉裁定不予受理)也“只愿意”(因和解协议本身对债权人实体权利有所削减,因此其不愿意越诉越不利)向法院申请恢复原生效法律文书的执行,导致另诉模式被架空。实践中,司法人员调研显示正是由于八成以上的和解协议都是申请执行人让步达成的,跟提起诉讼相比,申请恢复执行耗时短,成本低,在绝大多数情况下对债权的实现更有利,也更充分,因此就协议提起诉讼而导致大量诉讼、进而增加法院负担的可能性很低。反倒是对少数疑难复杂的和解协议,反复引发异议复议,甚至申诉信访,出于一些微妙的考虑因素如行政效率的考量,允许其通过另诉解决,解决得更彻底,成本也更低。因此部分学者所述被迫只能选择恢复执行的“困境”,在实践中似乎是件好事,因为另诉本身仅是针对部分疑难案件,至少相对于仅有恢复原执行这一条路径而言,其纾解了法院对无其他救济途径的当事人申诉信访压力。

关于就执行和解协议提起诉讼而言,原告也存在不同。在执行和解协议效力瑕疵时,《民诉法》241条赋予了申请执行人恢复原执行的权利,而在《执行和解规定》中赋予的是债务人、利害关系人等另诉以确认协议无效或撤销协议的权利,并最终导向债权人申请恢复原执行。两者看似殊途同归,但此时存在的争议是《执行和解规定》中允许债务人另诉已经能够满足需求还

是需要构建债务人异议之诉？支持另诉者称，只有在执行债权优于和解债权时，债务人异议之诉有其优势——因债务人异议之诉是债务人通过判决的方式排除执行名义的执行力，来确认执行和解协议中债权人真实的实体权利，而其他诉讼途径不具有排除执行名义执行力的效力。但是我国属于和解债权优于执行债权的模式，执行当事人之间在达成执行和解协议时对权利义务关系进行了重新安排，因此，只要通过另诉确认和解协议有效，即可自然阻却原执行名义的效力，无需构建额外的债务人异议之诉。支持债务人异议之诉者认为执行和解协议的效力瑕疵，本质上动摇了原执行行为的合法性与正当性。执行机关依据一个可能存在无效或可撤销事由的协议中止执行，本身属于不当执行，理应由专门的执行救济程序予以纠正。债务人异议之诉的优势在于，它能通过判决直接排除原执行名义的执行力，从根源上确认债权人在和解协议中的实体权利状态从而实现对执行行为与实体争议的一体化解决，为债务人提供更全面、彻底的救济。从实务角度出发，由于执行救济制度尚没有设立债务人异议之诉，当事人另诉救济不过是该情况的权宜之计，不仅缺乏明晰的裁判规则支持，执行程序是否继续也会对当事人的诉讼主体地位和举证责任分配产生较大影响。而债务人异议之诉作为执行程序的派生诉讼，与执行程序的衔接是顺畅的——如该诉讼的原告通常为债务人即被执行人，被告为债权人即申请执行人；同时，债务人作为原告一方，举证责任往往更重，有利于平衡双方权益。加上实践中还存在当事人恶意串通利用执行和解损害第三人利益，并且对此类情况的司法审查比较困难，而通过异议之诉制度确实可以在一定程度上弥补救济不足的缺陷的基础上，还能使执行救济体系更加符合逻辑，更可以避免导致诉又诉的发生。

2. 恢复执行的理论基础与制度边界

作为曾经唯一规定的救济方式,恢复执行起到了在当事人不履行或者不完全履行执行和解协议或者申请执行人因受欺诈、胁迫而达成与自己的真实意思表示不相一致的执行和解协议的时候保护当事人的作用。恢复执行的前提是原执行已经中止，否则无需恢复这一说。反对执行和解协议可诉的观点认为其违反“一事不再理”原则，而且并未使得债权人更加有效地实现权利。司法实践中也存在假借执行和解名义，实现偷偷转移财产的目的，而恢复原生效法律文书变成了很难兑现的“空头支票”。支持另诉确实存在与第9条矛盾的点——即恢复原执行和另诉都是法定的救济途径，甚至恢复执行是曾经唯一正当的途径，那么为何不能恢复执行原生效法律文书，也即救济顺序之间存在张力。比较惯常的解释就是实体程序二分法：似乎对于这种以物抵债协议申请执行人无法恢复执行原生效法律文书，实则债权人的实体请求权与强制执行请求权是相互独立的。质言之，法院生效裁判作出后，虽然其所载的债权人与债务人实体关系可能发生更改，例如债务人已经部分履行了债务以及双方就债务的履行期限等问题进行了进一步协商，但这些不能直接导致依附于执行依据的强制执行请求权消灭。矛盾的点在于，这种观点既然承认执行和解协议的私法性质，却又不赋予其救济权利，反而使其与原生效裁判处在永久的对立中。而比较有力的说法是从程序法的角度，坚持认定执行和解协议的达成是为了实现权利，而允许其又和解又诉讼的方法可能会导致和解诉讼无限循环。若要坚持执行和解的公法性质，凭借和解协议执行力否定说以及债务人异议之诉在规范上并不存在，可以得出唯一合理有效的救济途径就是恢复执行这一观点。这种对执行和解公法性质的强调，正是基于对纯粹的或者严格意义上的执行和解的观点上，即执行和解本质来说是在公法的指导下用来实现当事人的权利义务。执行和解协议的达成理应在原生效裁判的约束下，而不应新增各种与执行文本已确定的权利义务不同的内容。在这种意义上，新债清偿型执行和解协议是真正意义上的执行和解协议，而债务更新型执行和解协议不过是因实践中当事人之间千奇百怪的约定而产生的变体。面对双方当事人想通过执行和解协议的达成把之前的有的、潜在的甚至不存在的纠纷一并解决，债务更新型和解协议有了其生长的土壤，而给予这类执行和解协议以另诉权也是无奈之举，否则单纯的恢复原执行无法在法理上令人接受和实践中说服当事人。

虽然仅允许恢复原执行与规范不符，但可以理解的是这是一种站在应然上的执行和解协议救济方法。哪怕执行和解协议在实然上已经偏离了其轨道，也不能否认坚持恢复执行的底线价值。从制度功能来看，恢复执行这一选择为当事人意思自治划定了边界——它警示当事人，尽管法律尊重其通过执行和解协议重新安排权利义务的自由，但这一自由并非毫无限制，也即一旦执行和解协议未能履行，程序将自动回归到通过国家公权力保障债权实现的轨道。这种制度设计既保障了债权实现的效率，也体现了民事执行程序中公权力对私权处分的适当干预。

3. 以物抵债执行和解协议违约救济的类型化处理

实体 程序	新债清偿型（处分型）执行和解协议	债务更新型（创设型）执行和解协议	新债旧债关系约定不明
约定仅能另诉	原则上恢复执行	仅能另诉	同新债清偿型
约定仅能恢复执行	仅能恢复执行	仅能另诉	同新债清偿型
约定既能另诉也能恢复执行	原则上恢复执行	仅能另诉	同新债清偿型
无明确约定	仅能恢复执行	仅能另诉	同新债清偿型

实体

程序新债清偿型（处分型）执行和解协议债务更新型（创设型）执行和解协议新债旧债关系约定不明

约定仅能另诉原则上恢复执行仅能另诉同新债清偿型

约定仅能恢复执行仅能恢复执行仅能另诉同新债清偿型

约定既能另诉也能恢复执行原则上恢复执行仅能另诉同新债清偿型

无明确约定仅能恢复执行仅能另诉同新债清偿型

表1

首先，在明确约定既能另诉又能恢复执行这种契合实定法选择，或者约定仅能另诉的情形下（约定另诉），考虑到前述新债清偿型（处分型）执行和解协议诉讼标的具有同一性，若允许另诉则有违反“一事不再理”原则的危险。不过需要意识到，此时当事人根据处分原则并在符合诉讼法的规定下形成了一个独立的诉讼契约，且并不存在法定无效事由。在这样一种实体约定与程序契约复合而成的以物抵债执行和解协议，本身即是一种独立的合同类型，根本不同于传统民法意义上的和解合同、新债清偿等。换言之，此时加入了程序契约这一变量，另诉的请求权基础并不是原裁判所确定的权利义务，而是这份独立的以物抵债执行和解协议，因而并不违反既判力的消极作用。其次，在新债清偿型执行和解协议中无明确程序选择约定时另诉无法成立（法定另诉）。毕竟在此种协议中旧债仍然处于存续期间，若债务人对新债无法履行，恢复对旧债的执行是应有之义，且另诉可能导致程序冲突与冗余，使得问题愈加复杂。申言之，新债清偿型执行和解协议引发的后诉在虽然在旧实体法说下可以依赖“新事实”来提起另诉，但是在二分支说下引入诉的利益之考量后，可以发觉恢复原执行是更优的选择，另诉缺乏必要性

。此时应该坚持以恢复执行作为首要选择。但是这也不是完全禁止另诉，否则与实定法相矛盾，且前段所述从某种意义上可以得出所有执行和解协议均有可诉性的结论，只不过是经过了多重利益衡量与筛查后才得出恢复执行是取乎其上的选择。总之，对于提起另诉的前置要件是当事人在执行和解协议中明确这一程序变量，以增强其正当性。最后，在明确约定仅能选择恢复执行时，虽然新债在形式上仍然存在，但申请执行人通过执行契约放弃了对自身固有的程序选择权，那么此时仅允许其恢复原执行才能既不至于打破对方之程序期待，又能避免恢复执行与另行起诉可能带来的程序冲突与衔接困难。在以上论述基础上，考虑到当事人有可能在实体法上对旧债关系约定不明，而仅就执行契约进行了明确约定，综合本文第二部分对新债清偿本质的论述，依推定规则在实体法上其被视为新债清偿型以物抵债协议，相对应的救济模式参照处理即可。

债务更新型执行和解协议一般仅能另行起诉，毕竟其对于民事权利义务的变更不仅发生在辩论终结后，还超出了原裁判确定的范围。由于当事人已经合意将和解债权代替了生效债权，恢复执行原债权与当事人实体意思自治存在矛盾。例如在中某等执行审查类执行裁定书中，双方在执行和解协议中明确约定变更生效裁判所载的权利义务，且明确任何情况下，各方均不得恢复原生效裁判的执行，包括一方未履行或瑕疵履行和解协议的情况，法院在认定该协议合法有效的基础上，肯定了当事人达成合意用新债替代旧债，并非否定原生效裁判的法律效力，只是对各自依法享有的民事权利作出新的安排和处分。那么在此情况下，一方当事人再申请恢复旧债的执行，没有法律依据。至于当事人约定既可以另诉也可以恢复执行、约定仅能恢复执行或者无明确约定（按照法定规则），哪怕根据前述程序契约抑或独立合同原理也能强行论证其应该也可以恢复执行，但考虑到现实的约定以及履行情况，其旧债基础已经被合意消灭，故根本无法恢复一个在实体法上已经消灭的债务，且现实情况中大多数是因为旧债本身无法实际履行才会出现债务更新型执行和解协议，若仍然僵硬地看待当事人的约定条款，则只会造成申请执行人权利的进一步损失。

（三）超越双轨制：以物抵债执行和解协议执行力的有限承认

执行和解协议本身（有限的）可诉性已经得到法律规范的认可，该部分从立法论的角度对其执行力的探讨，希冀有助于更好地理解现行法关于执行和解协议救济模式的规定。

1. 执行力肯定说及其逻辑困境

该说比较直接的解释是有执行力的执行和解协议，作为原判决所确认的权利之具体实现方案，其本身承载着判决的执行力。质言之，当事人通过合意将判决的执行力固定地派生在了执行和解协议上，而其执行力并非独立于判决执行力。直接赋予执行和解协议执行力，实现其对原生效法律文书执行力的替代，就不会存在执行债权与和解债权相互抵扣的问题。从一行为两性质出发，法院必须尊重当事人对自己权利义务以及程序选择所行使的处分权，如若简单地因为债务人不履行该协议而简单认定其为无效，非常不利于对债权人的保护。从这一点出发，可以将执行和解类比诉讼和解，即诉讼和解协议通过司法确认程序转化为调解书从而具有既判力与执行力，执行和解协议同样也通过笔录及签字确认程序等公权力参与的模式，使其拥有执行力。

其次还有的运用对比的方式，即把民事和解、执行和解与诉讼和解中法院参与程度进行对比，认为我国执行人员往往会主动提示当事人解决执行争议的种种可能性，并积极劝说双方达成合意，与普通的民事和解而言，执行和解中执行法院的参与度更强。而其与民事审判中双方在法官前达成和解，并将内容载于笔录出具调解书的诉讼和解又没有本质区别。

再次一种间接承认和解协议执行力的方式是肯定和解协议具有否定执行名义执行力的功能。具体而言，被申请执行人可以主张和解协议抗辩，针对的是申请执行人就初始纠纷提起诉讼的诉的利益，应当在执行异议程序中加以提出，目的是为了消除原执行根据的执行力。该方法以《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第7条第2款为基础，在区分既判力基准时前后提出和解协议抗辩的基础上，较好地解决了原生效裁判与和解协议之间的矛盾关系。对于故意怠于提出和解抗辩对抗生效裁判，想获得双重给付的被执行人而言，在和解协议之诉中被申请人还可以和解协议抗辩使本诉的利益丧失，只能按照原生效裁判请求执行，遵循了“一事不再理”原则。

执行力肯定说的硬伤在于我国没有法律规范直接承认和解协议具有强制执行力，也没有一套将执行和解协议这一私契约转化为具有公文书效力的完备的司法审查程序。自2012年《民事诉讼法》修改时，对该问题从法理上已有权威解释：“如果和解协议具有了执行力，则意味着执行程序可以改变生效裁判的内容，那审判与执行分立的基本司法体制将面临崩溃的危险”。结合目前《执行和解规定》的恢复执行或另诉的救济模式来看，没有提及任何关于直接执行和解协议的表述。执行和解执行力肯定说的学者们在论述和解协议拥有执行力时也存在一些内部无法调和的矛盾，要么需要其依附于原生效裁判，要么要通过间接否认原生效裁判的执行力，即用诉讼程序（异议之诉或和解协议之诉）提出抗辩的方式等“立靶子”的方式来证明自身的执行力，而无法直接承认和解协议自生效就带有正当的执行力，更加彰显了这种理论之脆弱性。

2. 执行力否定说及其固有缺陷 最早的执行力否定说根源于执行和解的私法行为说，对于违反执行和解协议的强制执行，救济方法仅能通过实体法上债务不履行的损害赔偿请求权，而不能利用强制执行法有关执行异议等救济手段。这种观点其实不能说是对其执行力的否定，而是根本就无视了其公法上的性质，对执行和解协议的态度是非常保守的。

经过理论沉淀的执行和解协议执行力否定说已经发展认为执行机关与执行当事人达成的协议仅限于“民事执行权退出”，不包括“当事人不履行执行和解协议的，以执行和解协议为依据强制执行”。这种执行权与其说是退出，倒不如说是一种隐身，也即当事人履行执行和解协议，而一旦当事人不履行，其所附条件未得到满足，执行和解程序就应当终结，和解协议的使命也就完成了，更不能作为执行基础。当事人达成的执行和解协议只能约定变更执行依据的实现，不能约定可以请求以执行和解协议为依据强制执行，否则就会损害执行依据的既判力而无法通过执行机关审查。可以发现在执行力否定说中逐渐强调执行和解的公法性质，并给予私人意思自治“一次”解决纠纷的可能。换句话说，公法只给予私人自治一次机会，一旦当事人没有把握住这次机会，那么公法就可以撕破脸，直接恢复对原裁判文书的执行。

《民事诉讼法》241条规定的执行和解协议达成后经过执行员记入笔录的程序规定，也不代表对执行和解协议实质的审查和确认，其无法对执行和解协议所确立的实体权利义务承担高度证明作用。因为审查确认程序是非常严格的司法程序，我国现行法并没有相对完备的规范体系，显然无法将所谓记入笔录当做一项合格的司法审查程序。因此想通过论证经司法审查程序后的执行和解协议具有强制执行效力，在没有一套完备的审查体系下显得苍白无力。同时在笔者看来，哪怕设定了这样一套审查体系，作为审查执行者的执行法院，若在二审判决的执行程序中，使得当事人的执行和解协议拥有具有高度盖然性证明的公文书的效力，在我国现有法院组织架构看来存在以下犯上的嫌疑。

相似文献列表

去除本人文献复制比：3.9%(103)		去除引用文献复制比：0%(0)	文字复制比：3.9%(103)
1	执行和解协议中担保条款研究 - 道客巴巴 - 《互联网文档资源 (http://www.doc88.com) 》 - 2019	2.2% (58)	是否引证：否
2	执行和解协议中担保条款研究 刘君博；- 《法律科学(西北政法大学学报)》- 2019-06-11 1	2.2% (58)	是否引证：是
3	我国民事执行和解制度的困境与出路 黄光前(导师：李双元) - 《湖南师范大学硕士论文》- 2011-11-01	1.7% (45)	是否引证：否
原文内容			

3. 学说争论的启示及与有限承认路径的构建

那么这是否意味着肯定执行和解协议执行力没有任何价值呢？在经济因素限制、执行乱象丛生以及部分债务人道德欠缺等经济政治伦理因素影响下，执行和解本来应作为一种双方互相让步、更为快捷高效的争议解决方案，异化成了一种单方让步、另一方得寸进尺来实现拖延争议程序甚至获得双倍给付目的的制度。况且执行力否定说虽然很容易在规范和学理上占据优势，但并不意味着其本身不存在缺陷。虽然已经履行的和解协议根据《执行和解规定》第8条可以作执行结案处理，即可以受到法律保护，但没有履行的或者部分履行的却没有约束力，债权人要么请求执行原执行名义要么另诉，那么这一和解程序似乎是多余的，因为履行与否给这一协议的法律效果带来了翻天覆地的改变，还不如一开始就坚持执行原执行名义。这相当于只宣示了执行和解协议的私法效力，对实践中存在的问题解决没有益处。当然，不能一刀切地赋予执行和解协议以执行力，还需要进一步考察不同类型执行和解协议对于执行力的需求强弱。

对于新债清偿型执行和解协议，如前所述另行起诉缺乏必要的利益，原则上不应允许，因此在被申请人违约时留给申请执行人的选择就是恢复原执行或直接执行和解协议。考虑到债务人一般责任财产不足以清偿原金钱债务而作为抵债物之特定物仍存续且未被转移的情况，继续执行和解协议能够避免债务人私下转移金钱债权而导致恢复执行落空的风险，使债权人通过执行程序直接获得特定物的给付，更彻底地解决纠纷。然而对于新债清偿型执行和解协议仍然需要坚持恢复原执行优位的原则，毕竟赋予执行和解协议直接执行力有违审执分离的制度安排，且此时由于原判决确定的权利义务存续，无论其实际履行是否可能，若赋予新的执行和解协议以执行力，相当于未经审判程序而创设了一份新的执行依据，造成债权人请求双重给付的风险。此时造成的效果与允许申请执行人以执行和解协议另诉后得到一份新的执行根据没有实质上的差别，故前文对另诉不妥的分析均可适用于此处。总之，在新债清偿型执行和解协议中，要恪守恢复执行的原则，即使出现了可以赋予执行和解协议执行力的必要，也要结合提起另诉的情况以严格审查适用条件，防止出现实质利益失衡的现象。

债务更新型执行和解协议在经审判程序确认、赋予当事人充分的攻击防御机会之后，于执行阶段还被赋予创设实体法上新权利义务之效力，此制度设计本身已体现了对被执行人权益的充分考量。倘若在此基础上，仍赋予执行和解协议以另诉方式寻求救济，则为滥用诉权以拖延执行打开了方便之门，这不仅会造成前后程序的叠床架屋，降低纠纷解决的整体效率，更将不当牺牲申请执行人的期限利益，使其经生效裁判确认的权利处于长期悬置的不确定状态，变相拖延了申请执行人债权的实现，有过分保护被执行人之嫌。在这种债权人权利既无法恢复执行又难以另诉的真空地带，笔者认为在合理运用司法审查机制并对当事人程序权益进行规范保障的前提下，可以有限承认债务更新型执行和解协议执行力。正如学者指出，执行力的正当性基础主要是通过保障程序主体在参与生效法律文书最终形成的程序奠定的，当事人的程序保障构成了其实质性根据。至于如何完善司法审查机制，在案件经过了二审终审，尤其是该种变更了原裁判确立的权利义务关系的债务更新型执行和解协议，为了不造成执行法院与二审法院的冲突，首先，笔者认为可以在执行法院对该执行和解协议实质审查的基础上，设置一道专门的确认程序，即报请二审法院确认审查程序合法合理的背书程序。此报请确认程序并非简单备案，而是由审判权对执行权的关键环节进行事中监督，其功能类似于对一项新裁判的“一审”，以此确保实体结论的公正性，从源头赋予其正当性基础。其次，为了防止债务人或案外第三人的利益得到侵犯，同时维护债务人的审级利益，必须配套健全的异议之诉机制，其功能类似于针对该报请确认程序的“二审”。最后，赋予执行和解协议以执行力，这意味着执行和解协议能够成为新的执行名义，并且具有终结原执行依据执行程序的效力，可以彻底阻断债务人双重给付之风险。在强调效率的执行程序中，这一确认程序完全可以在该协议记入笔录后进行，并在当事人可能发生争议之前完成，此举既通过严密的程序设计维护了债务人的诉讼权利，又符合执行效率原则。

面对破坏审执分离原则的质疑，也可以通过现行法规范以及债务更新型执行和解协议本质加以考察以回应。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第37条以及《民事诉讼法》249条，可以通过对债务更新型执行和解协议以“公证赋强”的模式来获得其执行力，明确其执行名义的地位，当然前提是需要满足公证法规定的法定要件。在这之后若债务人仍不履行执行和解协议，债权人可以直接依据执行证书以及赋强公证书向法院申请强制执行，并不违背审执分离的原则，实践中也有法院对这种做法予以认可并发布相关指导。同时这种公证赋强的模式并不适用于新债清偿型执行和解协议，理由仍然存在于存续的具有执行力的旧债，而债务更新型执行和解协议因为旧债消灭，天然不存在此种矛盾，使得赋强程序能够得以顺利运行。

五、结语

实践中的以物抵债执行和解协议面貌多种多样，本文进行的分类初探只不过是管窥蠡测，仅及现实之一隅，这也是本文的不足之处。无论是对以物抵债还是执行和解的性质与协议类型进行怎样的划分，都体现出：社会生活的多样性，当事人合意的多种可能性，实践中的以物抵债和执行和解本身的复杂性，而作为其交叉领域的以物抵债执行和解协议自不待言。实体法学者

对以物抵债协议与和解合同言之甚多，而对执行和解协议关注甚少，需要诉讼法学者对其探索。在这过程中又不得不参考和借鉴实体法学者对以物抵债协议和和解合同性质的分析，并存在采用民法中“通说”的解释方案，却不足以完全呈现以物抵债执行和解协议真实面貌。尤其是到了在恢复执行与另行起诉徘徊之救济阶段，需要明确新债清偿型执行和解协议以恢复执行为主要救济路径，而债务更新型执行和解协议在解释论上仅能通过另诉救济，甚至通过赋强公证等方式获得有限执行力。为了实现强制执行法体系的自治，降低沟通成本与提高执行效率，有必要前述通过构建不同类型的以物抵债执行和解协议加以处理，在此基础上法院可以制作并提供载有不同救济方法的和解协议范本，并在结合法理与利益考量的基础上适用恰当的救济方式。最终，推动形成与协议类型精准适配的多元救济模式，是兼顾执行效率、程序公正与意思自治的必然方向，亦是为纾解执行困境、统一法律适用所提供的可行路径。

-
- 说明：1. 总文字复制比:被检测文献总重复字符数在总字符数中所占的比例
2. 去除引用文献复制比:去除系统识别为引用的文献后,计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例
3. 去除本人文献复制比:去除系统识别为作者本人其他文献后,计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例
4. 单篇最大文字复制比:被检测文献与所有相似文献比对后,重合字符数占总字符数比例最大的那一篇文献的文字复制比
5. 复制比按照“四舍五入”规则,保留1位小数;若您的文献经查重检测,复制比结果为0,表示未发现重复内容,或可能存在的个别重复内容较少不足以作为判断依据
6. 红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分
7. 系统依据您选择的检测类型(或检测方式)、比对截止日期(或发表日期)等生成本报告
8. 知网个人查重唯一官方网站:<https://cx.cnki.net>